

1501535-37.2021.8.26.0006

Classe: Termo Circunstanciado

Assunto: Contravenções Penais

Magistrado: José Ricardo Santini Antonietto

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Regional VI - Penha de França

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/06/2022

... condenação definitiva pelo crime de tráfico ilícito de drogas nos autos n.º 0032728-32.2009.8.26.0050 da 26ª Vara Criminal de São Paulo (fls. 61/62), pelo crime de porte ilegal de arma com numeração suprimida nos autos n.º 0051972-15.2007.8.26.0050 da 22ª Vara Criminal de São Paulo (fls. 62/63), pelo crime de roubo circunstanciado nos autos n.º 0093543-31.2004.8.26.0224 da 4ª Vara ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Regional VI - Penha de França

1ª Vara Criminal

Rua Dr. João Ribeiro nº 433, Sala 301 - 3º andar, Penha - CEP 03634-010, Fone: (11) 4635-8571, São Paulo-SP - E-mail: penha1cr@tjsp.jus.br

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo n.º:

1501535-37.2021.8.26.0006 - Termo Circunstanciado

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3048881/2021 - 24º D.P. PONTE RASA, 18465045 - 24º D.P. PONTE RASA

Autor do Fato e Denunciado:

Fábio Antonio de Brito e outro

Vítima:

SOCIEDADE

Data da Audiência:

14 de junho de 2022

Aos 14 de junho de 2022, à hora designada, na sala de audiências do Juízo de Direito da Primeira Vara Criminal do Foro Regional VI -Penha de França, onde presente se encontrava o MM. Juiz de Direito, Dr. JOSÉ RICARDO SANTINI ANTONIETTO, comigo escrevente ao final assinado, foi aberta a presente audiência de Instrução, Debates e Julgamento. Apregoadas as partes, compareceram o representante do Ministério Público, DR. ADOLFO SAKAMOTO LOPES, a ré THABATA VITÓRIA PEREIRA MELO e o réu FÁBIO ANTONIO DE BRITO, qualificados a fls. 1/2 dos autos, os quais declararam não possuir defensor, sendo então pelo MM. Juiz nomeado como defensor "ad hoc" o advogado plantonista, DR. ALEXANDRE DE PAULA ELCADRI, OAB/SP nº 347.144. Iniciados os trabalhos, pelo MM. Juiz foi dada a palavra ao defensor para que se manifestasse nos termos do artigo 81 da Lei nº 9.099/95 e pelo mesmo foi dito que: MM. Juiz, ausente justa causa, a peça preambular não deve ser recebida. Caso não seja esse o entendimento de Vossa Excelência, protesta a defesa pela inocência dos acusados. Logo após, pelo MM. Juiz foi dito que: Diante dos elementos contidos nos autos e da tipicidade, em tese, dos fatos narrados, recebo a denúncia oferecida contra os réus, por infração aos artigos 50, § 3º, alínea "a", e 42, incisos I e III, ambos da Lei das Contravenções Penais, c.c. os artigos 29, "caput", 61, inciso II, alínea "j", na forma do artigo 69, todos do Código Penal. Ato contínuo, foram ouvidas duas testemunhas de acusação, pelo sistema audiovisual, cujas qualificações seguem em apartado. Na sequência, foram realizados os interrogatórios dos réus, pelo mesmo sistema, cujos termos de qualificações também seguem em apartado. Pelo

MM. Juiz foi dito que por não haver mais provas a serem produzidas, dava por encerrada a instrução e determinava que se passasse aos debates. Pela ordem, foi DADA A PALAVRA AO DR. PROMOTOR e pelo mesmo foi dito que: MM. Juiz, THABATA VITÓRIA PEREIRA MELO e FÁBIO ANTÔNIO DE BRITO foram denunciados e estão sendo processados pela prática dos delitos de jogo azar e perturbação do trabalho ou do sossego alheios, em razão de no dia 13 de junho de 2021, por volta das 10h45, no interior do bar situado na Rua Cícero Paulo, n.º 22, Bairro Cangaíba, nesta cidade e comarca, agindo em conjunto e com unidade de propósitos: 1) exploraram jogo de azar, no qual o ganho e a perda dependiam da sorte, em lugar acessível ao público, sem o pagamento de entrada; 2) perturbaram a vizinhança e sossego alheio, mediante gritaria, algazarra e abuso de sinais acústicos. Os denunciados foram citados (fls. 95 e 97), apresentaram defesa prévia em audiência, nesta data a denúncia foi recebida e, durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas arroladas na denúncia e os réus interrogados. É o relatório. I. Preliminarmente, anota-se que a ré não compareceu em audiência preliminar e nem em audiência para o oferecimento da suspensão condicional do processo, apesar dos benefícios lhe terem sido ofertados. Em relação ao réu, qualquer benesse deixou de ser oferecida em razão de sua reincidência. II. No mérito, o pedido é PARCIALMENTE procedente. A materialidade da contravenção de jogo de azar é certa e está comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fl. 09, laudo pericial de fls. 30/37 que indicou a eficácia dos maquinários e que eram sorteadores de resultados, auto de depósito de fl. 45, auto de destruição de fl. 113, além da prova oral. III. A autoria também é certa e recaiu sobre os réus. Nesse sentido, a testemunha policial Júlio César Sotero dos Santos relatou: "Foi uma ocorrência irradiada via COPOM, inicialmente como perturbação do sossego, não sabíamos das máquinas caça niqueis. Chegando no local, eles fecharam a porta do bar. No entanto, esqueceram uma caixa de som para fora. Então eles abriram a porta para pegar a caixa de som. Alguns frequentadores saíram do local. Um casal se apresentou como responsável pela caixa de som e pelo local. Perguntamos se poderíamos entrar e eles autorizaram. Encontramos duas máquinas caça niqueis ligadas, mas sem apostador. Apresentamos o caso no 24º DP e o delegado requisitou perícia. Uma viatura ficou no local preservando. Eles disseram ser os responsáveis pelas máquinas. Não lembro se disseram ser dono das máquinas. Ele disse: 'se está no meu bar eu sou o responsável'. Não os conhecia anteriormente. Havia muito barulho excessivo, é um local conhecido como de baile funk". A testemunha policial Thiago Sanches de Souza Ribeiro narrou: "Estávamos em patrulhamento e fomos acionados pelo COPOM para atender a uma ocorrência de perturbação do sossego. Chegando no local eles fecharam a porta, mas esqueceram uma caixa de som para fora. Depois eles abriram e os réus se apresentaram como responsáveis pelo local. No bar havia duas máquinas caça niqueis, não havia ninguém na hora jogando. Foi requisitada perícia e encontraram vinte e seis reais dentro delas. Havia bastante barulho e volume razoavelmente alto proveniente daquela caixa acústica. A caixa era grande. Eles estavam cientes, sabiam que eram ilegal e se apresentaram como donos das máquinas. Não os conhecia anteriormente e não tinha atendido outra ocorrência naquele bar. Lá uma rua no interior de uma comunidade". A ré informou: "No dia do ocorrido, eu sou a dona do estabelecimento, a gente estava fazendo uma festa, porque era minha renda. Se eu não fizesse algum evento não teria como eu ter renda. Fizeram a denúncia e a gente realmente estava com o som. Eles levantaram as portas, já tinha terminado. Eles nos xingaram. Fábio na época era meu namorado. Entraram e viram os caça niqueis e nos levaram para a delegacia. Quando eles chegaram o som já tinha sido desligado. Eles que abriram a porta. Depois de muitos xingos eles encontraram as máquinas. Fábio me ajudava em dia de movimento. Ele começou a nos ofender, a gente retrucou, quando ele olhou para o lado ele viu as máquinas e nos levou para a delegacia. Elas estavam ligadas. Não havia apostador. Meu amigo arrendou o bar porque foi preso, então peguei as máquinas para ajudar na renda. Eu era a responsável pelas máquinas, que pertenciam a Jurandir. Não conheço outra informação dele. O lucro era repartido meio a meio. O bar era meu. Fábio ajudava em finais de semana e feriado. Em dias com menos movimento eu tomava conta sozinha". O réu asseverou: "Eu estava lá mesmo no dia, o dono do estabelecimento era Thabata, eu era namorado dela, estamos separados. Em dia de

fluxo eu ajudava ela a ficar lá. Quando os policiais chegaram, um minuto antes já tinha abaixado a porta do bar. Eles levantaram a porta do bar, foram agressivos, disseram que iam bater na minha cara porque tinha antecedentes criminais. Ele disse que ia nos autuar pelas duas maquininhas e fomos para a delegacia. Tinha duas máquinas no bar. Não me recordo se estavam ligadas. Não tinha apostador. Quando eles chegaram a porta estava fechada. Eles que entraram sem a gente autorizar. Já tinha cessado o barulho e a caixa estava para dentro do bar. Não tinha nenhuma caixa do lado de fora, ela funcionou, teve som. Estava com barulho ao longo da rua toda, lá tem vários bares, coisa de loco a rua toda. Estava tendo fluxo. As máquinas pertenciam a Jurandir. Não sei como funcionava a divisão de lucro. Já conhecia os policiais anteriormente, eles já tinham me abordado anteriormente". Segundo a prova oral colhida, os réus eram os responsáveis pelo local, onde havia 2 máquinas caça níqueis instaladas e em funcionamento, das quais a perícia apontou a eficácia dos objetos. Ademais, o laudo pericial indicou que as máquinas eram sorteadoras de resultados, comprovando-se o jogo de azar. Assim, bem evidenciada a materialidade a autoria, mister a condenação dos acusados em relação ao jogo de azar. Com relação à contravenção penal de perturbação do sossego, no entanto, em que pese a existência de notícias de algazarra e barulho no local, é certo que não há testemunhas indicando ambos como autores de tais perturbações. Nenhum morador do local foi arrolado e ouvido, impondo-se a absolvição em relação a esta contravenção penal. IV. No que diz respeito à dosimetria da pena, as circunstâncias judiciais são desfavoráveis para FÁBIO em razão da quantidade de máquinas apreendidas e dos maus antecedentes por conta da condenação definitiva pelo crime de tráfico ilícito de drogas nos autos n.º 0032728-32.2009.8.26.0050 da 26ª Vara Criminal de São Paulo (fls. 61/62), pelo crime de porte ilegal de arma com numeração suprimida nos autos n.º 0051972-15.2007.8.260050 da 22ª Vara Criminal de São Paulo (fls. 62/63), pelo crime de roubo circunstanciado nos autos n.º 0093543-31.2004.8.26.0224 da 4ª Vara Criminal de Guarulhos (fls. 64), não levadas em consideração para fins de reincidência. Na segunda fase incidiu a agravante da reincidência em razão da condenação definitiva pelo crime de desacato nos autos n.º 0005815-06.2014.8.26.0028 do Juizado Especial Criminal de Aparecida, com trânsito em julgado para a defesa em 3 de maio de 2018 (fl. 61). Não incidiu a agravante da pandemia, já que não há comprovação de que se valeu da situação excepcional para praticar o delito. Não há atenuantes, já que não houve confissão por parte do acusado, causas de aumento ou de diminuição da pena. Em relação à THABATA, não há circunstâncias judiciais desfavoráveis e ela faz jus à pena base. Na segunda etapa incidiu a atenuante da idade e da confissão. Não incidiu a agravante da pandemia, já que não há comprovação de que se valeu da situação excepcional para praticar o delito. Não há causas de aumento ou de diminuição da pena. V. O regime penitenciário para FÁBIO, diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis e da reincidência em crime doloso exigem a fixação do regime inicial semiaberto e é incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou por sursis. Em relação a THABATA, possível a aplicação isolada da pena de multa. VI. Ante o exposto, requer-se a parcial procedência do pedido, para condenar os réus THABATA VITÓRIA PEREIRA MELO e FÁBIO ANTÔNIO DE BRITO pela prática do delito de jogo azar, com a absolvição em relação à perturbação do trabalho ou do sossego alheios nos termos do artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal. Em seguida, foi DADA A PALAVRA AO DR. DEFENSOR e pelo mesmo foi dito que: MM. Juiz, : a ação penal não merece prosperar. Em que pesem as provas colhidas nos autos, as mesmas não são suficientes para ensejar um decreto condenatório. Mostra-se incidente o princípio da presunção de inocência dos acusados, que deve conduzir à absolvição. No caso em tela, a ré Thabata declara ser moradora do estabelecimento. No andar térreo, onde funcionava o bar, objeto de acareação pelos policiais, sendo seu fruto de renda. No momento dos fatos a ré é convicta de que se tratava de uma abordagem policial acerca dos barulhos e incômodos na vizinhança. O fato de os policiais cumprirem a denúncia de perturbação de sossego não tinham por objeto a invasão em domicílio já que o modus operandi desta operação é apenas a advertência verbal sobre os fatos ventilados. Nota-se que o depoimento dos policiais é conflitante em razão das máquinas estarem ligadas e

com apostadores e nada justifica adentrar ao estabelecimento para forjarem um flagrante acerca de máquinas caça-níqueis. Quanto ao réu Fábio, a ré Thabata declara que por se tratar de local de trabalho, o mesmo participava ajudando em dias da semana onde o movimento era maior, não recebendo qualquer remuneração referente às máquinas, tendo declarado ainda não saber da divisão dos lucros já que eram destinados exclusivamente à ré Thabata para seu sustento e de seu filho. Sendo assim, Fábio era tratado no estabelecimento como um funcionário. Não sendo este o entendimento de Vossa Excelência, requer-se a aplicação de pena substitutiva não privativa de liberdade. Por estas razões, requeiro a improcedência da presente ação penal e a ABSOLVIÇÃO dos réus nos termos do art. 386, do CPP. Após, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte sentença: "Vistos. Trata-se de ação penal pública movida contra THABATA VITÓRIA PEREIRA MELO e FÁBIO ANTÔNIO DE BRITO, qualificados nos autos, como incursos no art. 50, § 3º, alínea "a", e art. 42, incisos I e III, ambos do Decreto-lei nº 3.688/41 (Lei das Contravenções Penais), c.c. os arts. 29, caput, e 61, inciso II, alínea "j", na forma do art. 69, do Código Penal, sob a acusação de, no dia 13/06/2021, por volta das 10h45min, no interior do bar localizado na Rua Cícero Paulo, 22, Cangaíba, nesta Capital, previamente conluiados e com unidade de propósitos, explorarem jogos de azar em lugar acessível ao público, por meio de duas máquinas caça-níqueis, tendo ainda perturbado a vizinhança e o sossego alheio, mediante gritaria, algazarra e abuso de sinais acústicos, de acordo com a denúncia de fls. 84/86. Sem relatório (art. 81, § 3º, da Lei nº 9.099/95). Decido. A ré Thabata não foi localizada para a audiência preliminar (fls. 78/79) e não compareceu à audiência em que lhe seria formulada a proposta de suspensão condicional do processo, apesar de citada e intimada para tanto (fls. 94/95 e 102), enquanto o réu Fábio não fez jus a nenhum benefício, por ser reincidente (fls. 48/65 e 82/83, item 2, parte final). A ação penal é procedente em parte. Com efeito, a testemunha Júlio Cesar Sotero dos Santos, policial militar, disse que no dia dos fatos foi acionado, via Copom, para atender uma ocorrência de perturbação do sossego, sendo que ao chegar ao local indicado, um bar, a porta foi fechada, tendo ouvido barulho muito alto proveniente dele, sendo esquecida uma caixa de som enorme fora, com cerca de um metro e meio de altura. Os próprios frequentadores do bar abriram a porta para recolher a caixa, quando então perguntou quem eram os responsáveis pelo local, tendo os réus se apresentado como tais e franqueado a entrada. Ao revistar o bar, localizou duas máquinas caça-níqueis, ligadas na ocasião mas sem apostadores, tendo os réus informado que eram os responsáveis por elas, sendo o local preservado para a perícia. Informou que aquela rua é conhecida como ponto de bailes funk, não conhecendo os réus antes dos fatos. A testemunha Thiago Sanches de Souza Ribeiro, policial militar, disse que no dia dos fatos foi acionado, via Copom, para atender uma ocorrência de perturbação do sossego, sendo que ao chegar ao local indicado, um bar, as portas foram fechadas, sendo esquecida contudo uma caixa de som grande na calçada, dando para ouvir um barulho alto proveniente dela, além do falatório das pessoas. A porta do bar foi reaberta para o recolhimento da caixa, quando então perguntou quem eram os responsáveis pelo local, tendo os réus se apresentado como tais e franqueado a entrada, sendo encontradas duas máquinas caça-níqueis, ligadas na ocasião mas sem apostadores. O local foi preservado para a perícia, que encontrou R\$ 26,00 dentro das máquinas, tendo ambos os réus dito que elas lhes pertenciam, não os conhecendo antes dos fatos. A ré Thabata, em seu interrogatório na esfera policial, optou pelo silêncio (fls. 4/5). Em Juízo, disse ser a dona do bar, onde estava havendo uma festa, pois era sua fonte de renda, tendo vizinhos acionado a polícia em razão do excesso de barulho, pois havia som ligado. Informou que quando a polícia chegou o som já tinha sido desligado, tendo os policiais levantado a porta, que já estava fechada, sendo localizadas duas máquinas caça-níqueis, ligadas na ocasião mas sem apostadores, as quais pertenciam a um homem chamado Jurandir, com quem dividia o lucro pela metade. Disse ter sido ofendida pelos policiais, sendo Fábio seu namorado na época, o qual a ajudava quando tinha mais movimento, como naquele dia. O réu Fábio, em seu interrogatório na esfera policial, optou pelo silêncio (fls. 4/5). Em Juízo, disse que o bar era de Thabata, sua namorada na época, costumando ajudá-la no local, onde no dia dos fatos houve um evento, com som ligado, contudo

quando a polícia chegou o som já tinha sido desligado e a porta sido fechada cerca de um minuto antes. Os policiais abriram a porta e foram agressivos, até por já ter antecedentes criminais, sendo encontradas duas máquinas caça-níqueis dentro do estabelecimento, sem nenhum apostador, não lembrando se elas estavam ligadas, as quais ao que parece pertenciam a um homem chamado Jurandir. Informou que quando os policiais chegaram o barulho já tinha acabado, não havendo nenhuma caixa de som na calçada, estando todos os objetos dentro do bar, sendo que naquele dia havia festa na rua toda, em vários bares, com carros de som inclusive, mesmo em plena pandemia. Disse já ter sido abordado pelos mesmos policiais antes dos fatos. Portanto, a prova oral permite concluir com segurança que os réus praticaram a contravenção penal prevista no art. 50, § 3º, alínea "a", de Decreto-lei 3.688/41, que lhes foi imputada na denúncia, na medida em que eram os responsáveis pelo bar onde foram apreendidas duas máquinas caça-níqueis, as quais, segundo disseram aos policiais, lhes pertenciam, informando em Juízo contudo que pertenciam a um homem chamado Jurandir, o que contudo não tem relevância maior, pois o que importa na realidade é a exploração dos equipamentos, o que foi confessado. A materialidade de tal contravenção está demonstrada pelos autos de exibição e apreensão (fls. 9) e laudo pericial (fls. 30/37). A perita descreveu com pormenores a situação do local e das máquinas apreendidas, que estavam operantes e funcionavam a contento, destinando-se à realização de típicos jogos de azar, onde o ganho ou perda não dependem da habilidade física ou intelectual do apostador, mas exclusivamente da sorte. No que diz respeito contudo à contravenção de perturbação de sossego, prevista no art. 42, incisos I e III, do Decreto-lei nº 3.688/41, entendo não haver prova suficiente para a condenação, uma vez que nenhuma testemunha demonstrou tal prática por parte dos réus, existindo apenas referência genérica a algazarra que havia no local, não se sabendo contudo por parte de quem, tendo sido neste mesmo sentido inclusive o parecer do representante do Ministério Público. Resta a dosagem das penas. Ré Thabata: Atento ao disposto no art. 59 do Código Penal, fixo a base no mínimo de 3 meses de prisão simples e 10 dias-multa. O valor do dia-multa, nos termos do art. 60 do Código Penal, é estabelecido em 1/30 do salário mínimo em vigor na época do fato, diante da condição financeira da agente. Prejudicada a atenuante da confissão, por ter a pena sido fixada no mínimo legal (Súmula 231 do STJ). Não há circunstâncias agravantes, não incidindo, a meu ver, a prevista no art. 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, pois a pandemia da COVID-19 não contribuiu para a prática contravencional, não existindo relação entre elas. Não há causas de aumento ou diminuição. Presentes os requisitos legais, substituo a pena privativa de liberdade por multa (art. 60, § 2º, do Código Penal), na mesma quantidade e valor unitário. Réu Fábio: Atento ao disposto no art. 59 do Código Penal, fixo a base no mínimo de 3 meses de prisão simples e 10 dias-multa. O valor do dia-multa, nos termos do art. 60 do Código Penal, é estabelecido em 1/30 do salário mínimo em vigor na época do fato, diante da condição financeira do agente. Dou por compensadas a agravante da reincidência com a atenuante da confissão, não havendo, a meu ver, que se falar na agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, pois a pandemia da COVID-19 não contribuiu para a prática contravencional, não existindo relação entre elas. Não há causas de aumento ou diminuição. Observo que o art. 60, § 2º, do Código Penal, autoriza a substituição da pena privativa de liberdade não superior a seis meses por multa, "observados os critérios dos incisos II e III do art. 44 deste

Código". À primeira vista, portanto, o reincidente em crime doloso não poderia receber tal benefício (art. 44, inc. II, do CP). Mas, segundo a doutrina que se adota: "... o § 3º do art. 44, ao tratar das penas restritivas de direitos, abrandou esta regra, dispondo que 'se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, desde que, em face da condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime'. Ora, se para a condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos (art. 44, § 2º, primeira parte, do CP), ainda que o condenado seja reincidente genérico em crime doloso (art. 44, § 3º), por equidade o mesmo critério deve ser aplicado na substituição de condenação não superior a seis meses por multa (art. 60, § 2º)"

(CELSO DELMANTO e outros autores, Código Penal Comentado, Saraiva, 2010, pág. 284). Assim, levando-se em conta tratar-se de mera contravenção penal, entendo cabível a substituição da pena privativa de liberdade por multa (art. 60, § 2º, do Código Penal), na mesma quantidade e valor unitário. Isto posto, julgo parcialmente procedente a ação penal movida contra THABATA VITÓRIA PEREIRA MELO e FÁBIO ANTÔNIO DE BRITO e condeno-os ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo em vigor na época do fato, com correção monetária desde então, como incursos no art. 50, § 3º alínea "a", da Lei das Contravenções Penais, c.c. o art. 29, caput, do Código Penal. Outrossim, absolvo-os da acusação da prática prevista no art. 42, incisos I e III, da Lei das Contravenções Penais, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Transitada em julgado, manifeste-se o Ministério Público, em cinco dias, sobre o destino das máquinas apreendidas. Decorrido o prazo sem oposição, determino a destruição, oficiando-se para tanto. No que se refere ao valor em dinheiro apreendido, com fundamento no art. 91, inc. II, "b", parte final do Código Penal e 119 do Código de Processo Penal, determino a perda em favor da União. Recolha-se. Oportunamente, lancem-se os nomes dos sentenciados no rol dos culpados. Dada e publicada em audiência, saem os presentes intimados desta sentença. Cumpra-se". Nada mais. Encerrou-se o presente termo que depois de lido, vai devidamente assinado. Eu, _____ (Josiel Silveira Rosa), escrevente, digitei e subscrevi.

DR. PROMOTOR:

DR. DEFENSOR DOS RÉUS:

RÉ THABATA:_____

RÉU FÁBIO:_____